

[16] [개선] 사항

1. 제 목 : 부분 준공된 공사의 공사이행보증 적용 범위 불합리
2. 조치부서 : △△단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 조달계약을 체결함에 있어 「국가계약법 시행령」 제50조에 따라 계약 상대방에게 계약금액의 100분의 10 이상을 계약보증금으로 납부하도록 하고, 제 51조에 따라 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때는 계약보증금을 귀속하고 있다.

아울러, 工事 계약의 이행보증은 「국가계약법 시행령」 제52조에 따라 계약 상대방으로 하여금 계약금액의 100분의 15 이상을 계약보증금으로 납부하는 방법과 공사이행보증서³⁶⁾를 제출하는 방법 중 하나를 선택하도록 하되, 추정가격 300억 원 이상인 공사 등에 대해서는 반드시 공사이행보증서를 제출하도록 하고 있다.

한편, 공사이행 보증을 계약보증금으로 납부한 경우, 계약상대자가 계약 이행을 정당한 이유 없이 이행하지 아니할 경우 계약보증금을 귀속하여 ‘손해배상액의 예정’ 또는 ‘위약벌’의 성격으로 처리하지만,

36) 해당 공사의 계약상의 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70 미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50) 이상을 납부할 것을 보증

공사이행보증서를 제출한 계약은 「국가계약법 시행령」 제2조에 따라 보증기관으로 하여금 계약상의 의무를 이행하도록 하되, 이를 이행하지 아니할 경우 일정 금액을 납부토록 하고 있어 계약상대자의 계약 미이행에 따른 처리 방법이 다소 다르다.

아울러, 「정부 입찰·계약 집행기준」 제43조에 따르면 공사이행보증서의 보증채무에는 하자담보채무를 포함하지 아니하되, 계약 체결 시 하자담보채무에 대하여 별도의 특약을 체결한 때에만 이를 포함한다고 규정하고 있다.

따라서 「공사계약 일반조건」 제28조 및 제29조에 따라 목적물에 대한 검사 등의 절차를 거쳐 公社에서 工事 계약의 일부를 준공(이하 ‘부분 준공’이라 한다)하여 해당 목적물을 인수하였다면, 이는 해당 목적물에 대한 계약상 의무 이행이 완료된 것으로 보는 것이 타당하며, 향후 동일 목적물에 대해 계약상 의무 불이행이 발생한다고 볼 수 없다.

따라서 당초 工事 계약 내용 중 관련 법규 및 계약조건 등에 따라 부분 준공된 (하자이행보증서 발급 및 목적물 인수 등) 물량은 공사이행보증 대상에서 제외하고, 잔여공사에 대해서만 공사이행보증서를 제출하도록 하는 것이 합리적이다³⁷⁾.

아울러, 공사기간 연장 등에 따라 추가 발생하는 공사이행보증서 발급 비용은 「공사계약 일반조건」 제23조 및 「설계변경 등 계약금액조정기준」 4.3.6.에 따라 公社가 계약상대자에게 실비로 지급하여야 함에 따라 부분 준공 물량 등을 보증범위에 포함시킬 경우 불필요한 예산 지출을 야기할 수 있다.

37) 공사이행보증서 발급 대상이 되는 공사의 범위는 ‘부분 준공된 부분을 제외한 나머지 공사’로 보는 것이 타당 (감사자문단 사내변호사 자문, 2017.8.28.)

실례로 감사기간 중 수도권 지역을 대상으로 부분 준공된 工事 계약의 공사이행보증 현황을 조사한 결과, [표 42]와 같이 전체 공사에 대해 공사이행보증이 이루어지고 있어 잔여 工事에 대한 공사이행보증 대비 약 598백만 원의 비용이 추가 발생하고 있다.

[표 42] 부분 준공 工事의 공사이행보증서 발급 현황

공사명	공사 금액(백만 원)		공사이행보증서 발급비용(천 원)		
	전체	잔여	현재(전체)	조정안(잔여)	차이
인천** 조성공사 4공구	213,409	15,912	192,418	14,309	178,109
인천 **IC 및 **교차로	101,154	542	111,727	62,215	49,512
인천** 조성공사 1공구	118,743	6,606	53,071	8,601	44,470
화성**2 조경공사 3-1공구	28,421	17,392	178,757	109,389	69,368
화성**2 조성공사 1-2공구	106,464	21,686	243,571	38,657	204,914
화성**2 조성공사 3-1공구	77,120	3,718	45,080	2,174	42,906
화성**2 조성공사 3-3공구	38,254	1,053	9,630	265	9,365
합 계	683,565	66,909	834,254	235,610	598,644

자료 : 청라영종사업본부 및 ◆◆사업본부 제출자료 재구성

또한, 公社에서 부분 준공 물량에 대해 하자이행보증서를 징구하고 시설물을 인수하는 등 공사 이행이 완료되었음을 인정하고도, 전체 공사를 대상으로 공사이행보증을 요구하는 것은 계약상대자에 대한 불합리한 업무처리로 인식될 수 있다.

이에 대해 담당 부서인 △△단에서는 일건 계약의 원칙과 계약보증금을 손해 배상의 예정으로 보아 왔던 사내변호사 자문내용³⁸⁾ 및 법원 판례³⁹⁾에 따라 부분 준공 이후에도 전체 공사계약을 대상으로 공사이행보증을 처리하였으나,

38) 조경시설 설치공사에 대한 계약보증금 일부 반환 가능 여부 등(법무실 안*훈 변호사, 2017.3.2.)

39) 조경식재, 시설물공사와 식재유지관리공사를 구분하지 않고 이 사건 공사계약 전부에 대하여 이 사건 보증 계약이 체결된 것이므로 전체적으로 하나의 공사로 보아 보증금 귀속을 판단(서울중앙지방법원 2010.4.1.선고 2009가합111055 판결)

부분 준공 이후 하자이행보증서가 징구되었다면 공사이행보증의 실익이 없고, 향후 법적 분쟁 시 「민법」 제398조의 손해배상예정액 감액 법리에 따라 부분 준공된 부분은 감액될 여지가 있다고 판단되므로, 불필요한 예산낭비 방지 및 계약상대자의 입장을 고려한 방안 마련이 필요하다고 답변하였다.

따라서 공사이행보증서가 징구된 工事 계약 중 「공사계약 일반조건」 등의 절차에 따라 부분 준공 후 하자이행보증서가 발급 되었다면 잔여공사에 대해서만 공사이행보증이 이루어지도록 개선할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

△△단장은

「공사계약 일반조건」 등에 따라 부분 준공된 工事의 이행보증은 잔여공사에 대해 이루어지도록 공사이행보증 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(개선).